

1502289-38.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leonardo de Mello Gonçalves

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... portanto, incurso na prática do crime de tráfico e sujeito às penas a ele culminadas, mesmo que não tenha sido preso em flagrante fazendo a efetiva comercialização do entorpecente.

A atual e predominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a configuração do delito de tráfico não é indispensável que o agente efetue a comercialização da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

2ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-190

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502289-38.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502289-38.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2184190/2021 - 05º D.P. SANTOS, 18930475 - 05º D.P. SANTOS, 860/21/215 - 05º D.P. SANTOS, 2184190 - 05º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO SANTOS LUZ

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo de Mello Gonçalves

Vistos.

LEONARDO SANTOS LUZ, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado como incurso na prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Conforme narra a denúncia, no dia 07 de julho de 2021, no Caminho São José, 125, Radio Clube, nesta cidade e Comarca de Santos, o réu adquiriu e trazia consigo, para fins de comercialização, drogas proscritas no Brasil, nos termos da Portaria n. 344/98 - SVS/MS, e que determinam dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local dos fatos acima mencionadas, policiais militares encontrava-se em patrulhamento de rotina, quando avistaram o acusado em uma bicicleta, o qual, ao visualizar os policiais, abandonou-a e

empreendeu fuga correndo em desabalada carreira, seguindo em direção à comunidade ali existente (Caminho São José).

Consta que, durante a fuga, o réu dispensou uma sacola que trazia consigo, sob as roupas, a qual continha quarenta e dois pinos de cocaína (66g), um filete de maconha (9g), trinta e sete pinos contendo pó branco (63g); vinte e três porções de maconha (67g); vinte e nove pinos contendo cocaína (71g); cento e cinco pedras de crack (26g) e oito frascos de lança-perfume.

Auto de prisão em Flagrante (fls. 01). Boletim de ocorrência (fls. 07/10). Auto de exibição e apreensão (fls. 11/12). Laudos periciais (fls. 97/98 e 136/139).

O réu foi notificado (fls. 102/103) e ofertou defesa prévia (fls. 104/107).

A denúncia foi recebida em 14/09/2021 (fls. 114/115).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e três testemunhas de defesa, bem como foi realizado o interrogatório do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público, pugnou pela procedência da ação penal. Aduziu que materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas. Afirmou que os policiais militares foram categóricos ao narrar os fatos, bem como as circunstâncias da prisão do acusado. Disse que os policiais viram o réu dispensar a sacola com as drogas. Argumentou que as testemunhas de defesa são todas amigas do acusado, uma delas, inclusive é mãe do réu. Aduziu que a versão apresentada pelo acusado e pelas testemunhas de defesa é fantasiosa. Sustentou que não há motivos para duvidar das palavras dos policiais, tendo em vista que eles sequer conheciam o acusado, não havendo qualquer elemento nos autos que justifica a sua incriminação indevida. Aduziu que o réu é tecnicamente primário, não havendo impeditivo para redução da pena na forma do artigo 33, § 4º, da lei 11.343/06. Sustentou que deve ser aplicado o regime aberto para início de cumprimento de pena pelo o acusado, não sendo o caso de substituição da pena privativa de liberdade. Requereu a procedência da ação.

A Defesa, também em alegações finais, requereu a absolvição do acusado. Aduziu que houve contradição entre os depoimentos das testemunhas policiais. Falou que não conseguiram explicar o grande tempo entre a abordagem e a apresentação do réu na delegacia. Falou que apesar de os policiais falarem que o local dos fatos fica próximo a delegacia, os policiais levaram mais de uma hora para apresentá-lo na delegacia. Disse que as testemunhas de defesa descreveram como os fatos ocorreram, comprovando que o réu não estava com drogas. Falou que o acusado não possui qualquer passagem criminal, mesmo quando menor de idade, não havendo registro de ato infracionais, tendo bons antecedentes, não havendo qualquer indício para a prática criminosa.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo boletim de ocorrência de fls. 07/10, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e pelo laudo pericial dos entorpecentes de fls. 97/98 e 136/139, bem como pela prova oral colhida durante a fase de instrução.

A autoria do delito também é certa e atribuída ao acusado.

A testemunha LEONARDO DO NASCIMENTO, policial militar, disse que estava em patrulhamento próximo ao local dos fatos quando se deparou com o réu pedalando de bicicleta, que, ao visualizar o policiamento, começou a pedalar mais rápido. Falou que o acusado empreendeu em fuga, sentido Caminho São José e quando ele chegou na entrada desse Caminho, dispensou uma sacola. Disse que seguiu na perseguição do réu, enquanto o seu parceiro ficou no local onde a sacola foi dispensada. Falou que viu o acusado dispensando a sacola onde estavam as drogas. Afirmou que não se recorda da quantidade de drogas, mas que tinha grande variedade, entre maconha, cocaína, crack e lança perfume. Aduziu que não se recorda se havia outros elementos do tráfico, como anotações. Disse que nunca viu o réu antes dos fatos. Sustentou que o acusado afirmou que fugiu dos policiais por causa de um celular, mas não foi localizado qualquer aparelho, somente as drogas. Falou que o acusado não assumiu que estava traficando. Narrou que o réu dispensou uma sacola e que no interior dela havia outras sacolas com as drogas. Falou que era uma sacola tipo de supermercado.

Disse que no momento da abordagem estava em patrulhamento pelo bairro do Radio Club. Falou que nem ele e nem o seu parceiro deram tiro para o alto. Explicou que após a abordagem do acusado precisou chamar reforço de uma viatura para o encaminhamento dele à delegacia, pois estavam de motocicleta. Falou que antes da abordagem desembarcou da moto e perseguiu o acusado a pé. Disse que o local da abordagem é próximo ao local onde o acusado dispensou as drogas. Falou que não havia muitas pessoas no local onde a abordagem foi feita. Aduziu que levou o tempo normal do local dos fatos até à delegacia, que não fica muito longe. Falou que o tempo entre a prisão do acusado e o registro da ocorrência é o normal que o Distrito Policial leva para fazer o flagrante. Explicou que nunca teve qualquer problema com moradores da região.

A testemunha HEITOR ANTONIO DO VALE SILVA, policial militar, disse que estava em patrulhamento de rotina e quando o réu viu o policiamento e começou a pedalar mais rápido. Falou que em determinado momento o acusado dispensou a bicicleta e começou a fugir a pé e que seu parceiro fez abordagem na entrada da comunidade. Explicou que encontrou a sacola no chão e que havia no seu interior entorpecente, mas que não se recorda a quantidade, e que viu o réu jogando a sacola no chão. Narrou que o acusado, após sair da bicicleta, correu por alguns metros e depois tirou a sacola de dentro da roupa e jogou no chão. Disse que ao encontrar o entorpecente foi ao encontro de seu parceiro que estava com o réu. Afirmou que o acusado não confessou o crime. Narrou que não conhecia o réu antes dos fatos. Falou que somente foi atrás do acusado, pois ele fugiu ao ver o policiamento. Argumentou que o acusado dispensou a sacola na entrada de um beco. Explicou que ele dispensou somente uma sacola. Falou que pediu o apoio de uma viatura de área para conduzir o réu ao Distrito Policial. Disse que não se recorda com exatidão o horário da prisão, mas quem levou o réu para o DP foi a viatura e que ele e seu parceiro a acompanharam de moto. Falou que foi ele quem levou a sacola para a delegacia. Explicou que o réu nada tinha no momento da prisão, somente a sacola que ele havia dispensado. Falou que nem ele e nem seu parceiro deram tiro para cima. Sustentou que no momento da prisão do acusado não tinha muita gente na rua. Falou que pediu apoio após o acusado ser preso pelo seu parceiro. Explicou que nunca teve problema com pessoas que moram na região dos fatos.

A testemunha de defesa ALLAN GOÊS PEREIRA RAMOS disse que conhece o réu há um ano, pois jogava bola com ele no Dale Coutinho. Falou que estava no momento da prisão e que tudo ocorreu na porta da casa da sua mãe. Explicou que a casa da sua mãe fica em cima da comunidade e que tem duas entradas, sendo uma delas um corredor, por onde o acusado passou. Afirmou que o acusado estava a pé, sozinho, e que não viu com ele qualquer pertence. Falou que estava parado na porta da casa da sua mãe, com ela, quando escutou o barulho de um disparo, quando, segundos depois, viu o réu saindo do corredor que dá acesso à casa da sua mãe e logo em seguida veio um policial atrás dele, quando o policial pediu para o acusado parar. Explicou que o policial pegou o acusado e o levou para o corredor de onde os dois vinham. Disse que ficou de três a cinco minutos visualizando a abordagem e quando saiu o acusado ainda estava no local. Afirmou que viu somente o policial conversando com réu, que estava sentado no chão, mas não viu o momento em que ele foi conduzido. Falou que viu o acusado andando, quando saiu do corredor e, segundos depois, apareceu o policial que pediu para ele parar, quando ele parou e o policial o abordou, levando para o corredor por onde tinham passado. Explicou que estava por volta um metro e meio da abordagem e que o acusado não pediu a sua ajuda. Falou que a abordagem ocorreu em torno das 15h/15h30. Aduziu que depois, pela janela da casa da sua mãe, viu o policial perguntando para o réu onde estava o celular dele, mas o réu falou que não tinha celular. Falou que o réu não estava de bicicleta e que ele estava andando, a pé. Disse que não tem muito contato com o acusado.

A testemunha KELY CAROLINE DE JESUS NETO disse que conhece o réu desde pequeno, do bairro onde moram. Falou que no dia dos fatos estava na praça, com seu filho, que estava empinando pipa. Afirmou que viu o acusado na praça, montado na bicicleta, conversando com amigos. Explicou que os policiais chegaram na praça, deram um tiro para o alto, quando todo mundo correu. Aduziu que foi feita a abordagem e que os policiais falaram para sentar no chão, sobre as mãos. Argumentou que durante a

abordagem nada foi feito pelos policiais e que depois chegou uma viatura, quando o colocaram dentro do carro. Disse que no momento da abordagem conversou com os policiais, falando que o réu nada tinha feito. Falou que foi chamar a mãe do réu. Afirmou que da abordagem até o momento que ele foi conduzido pela viatura levou por volta de 15 minutos. Narrou que ficou no local até o momento em que o réu foi colocado na viatura, quando foi chamar a mãe dele. Disse que o réu não tinha qualquer sacola. Falou que na praça onde estava não tem ponto de tráfico e que lembra dos policiais, pois eles trabalham no bairro, bem como que eles fazem outras abordagens no local. Disse que, após a abordagem do réu, um policial ficou com ele e outro ficou andando pelas redondezas para ver se achava algo, mas que logo depois chegou a viatura. Falou que estava próximo ao local dos fatos e que no momento da abordagem o réu estava parado, conversando, sobre a bicicleta, quando os policiais chegaram. Disse que os policiais abordaram o acusado de forma rápida. Narrou que no momento da abordagem os policiais pediram para o acusado um celular, mas que ele não tinha o celular. Disse que havia várias pessoas no local, mas que o réu foi o único a ser abordado. Falou que o acusado não correu no dia dos fatos e que junto com o acusado tinham mais cinco ou seis pessoas, conversando, e que Allan estava próximo. Disse que acusado deixou a bicicleta no canto da praça. Falou que foi a primeira vez que viu o acusado sendo abordado pelos policiais, mas em todas as abordagens que fazem os policiais prendem alguém. Explicou que próximo à praça tem pontos de venda de drogas. Falou que o acusado é desempregado e que quem o sustenta é a mãe dele. Falou que o acusado sempre fica na praça e que ele nunca foi preso. A testemunha LUCIANA SANTOS DA LUZ, mãe do acusado, disse que, no dia dos fatos, deu R\$ 50,00 para o réu comprar uma cadeirinha de bicicleta para andar com o filho dele e que meia hora depois a testemunha Kely foi chamá-la, falando que seu filho havia sido preso. Disse que recuperou a bicicleta do acusado.

O réu, LEONARDO SANTOS LUZ, interrogado em Juízo, negou os fatos descritos na denúncia. Disse que saiu de casa para comprar uma cadeirinha para o seu filho, quando parou na praça e, logo em seguida, passaram os policiais, quando deram um tiro para o alto. Falou que após o tiro todo mundo correu, quando ele levantou da bicicleta e entrou no beco. Explicou que logo em seguida os policiais o abordaram perguntando onde estava a droga e o celular. Disse que não estava com droga ou celular, quando eles falaram para sentar no chão, sobre as mãos, quando um policial foi procurar as drogas e outro ficou com ele, falando no celular, chamando apoio de uma viatura, quando o outro policial que estava atrás da droga voltou e falou que ele estava preso em flagrante. Disse que depois foi colocado na viatura, quando os policiais de moto foram para um lado e a viatura ficou dando voltas em uma praça, e, após três ou quatro voltas, os policiais da viatura ligaram para os policiais das motocicletas, perguntando onde eles estavam, quando foi conduzido para o 5º DP. Falou que, na frente do 5º DP, conseguiu ver os policiais tirando duas sacolas de drogas de dentro do baú da moto. Disse que via os policiais constantemente, pois eles fazem patrulhamento pelo bairro. Afirmou que nunca foi abordado antes pelos policiais. Aduziu que não sabe o motivo dos policiais inventarem essa história contra ele. Falou que foi preso no beco e que frequentava o local, pois tem amigos que moram perto.

Este é o cerne do conteúdo probante angariado ao feito.

Vê-se, assim, que as provas colhidas são suficientes para a condenação do réu, pois foi adequadamente comprovado que este trazia consigo as drogas apreendidas para o fim de comercializá-las de forma ilícita.

Neste diapasão, as testemunhas policiais Leonardo e Heitor lograram êxito em descrever, de forma harmoniosa, a ação criminosa do réu, relatando que o motivo da abordagem foi a sua conduta suspeita.

A testemunha Leonardo afirmou que visualizou o acusado passando de bicicleta e que este, ao ver o policiamento, começou a pedalar mais rápido, o que chamou atenção, decidindo ir atrás dele. Disse, também, que viu o acusado jogar ao solo uma sacola plástica, onde estava a droga apreendida, explicando que a sacola foi localizada por seu parceiro, a testemunha Heitor.

Da mesma forma, a testemunha Heitor corroborou as palavras de Leonardo, também narrando a mesma dinâmica dos fatos, de modo que restou plenamente configurado que

o acusado era o proprietário das drogas encontradas no interior da sacola. Quanto ao valor do testemunho policial, é digno de notar que o artigo 202 do Código de Processo Penal determina categoricamente que “toda pessoa poderá ser testemunha”. Significa dizer que, ressalvado o disposto no artigo 206 do mesmo diploma, a profissão de determinada pessoa, seja ela da carreira policial ou não, em nada obsta a condição para testemunhar, devendo ser levado em conta que os agentes públicos prestam compromisso legal de dizer a verdade, possuindo fé pública.

O Colendo Supremo Tribunal Federal, inclusive, atribuiu idoneidade e presunção de veracidade à prova prestada por policiais, aduzindo, em entendimento pacificado, que “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC. nº. 74.608- 0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido frequentemente na mesma linha intelectual da Suprema Corte, porquanto: “Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021)

Com efeito, a idoneidade do depoimento policial só poderia ser questionada se houvesse indícios nos autos de injusta incriminação de inocente, o que não ocorre no caso sub examine, até porque as testemunhas relataram que nada tinham contra o acusado.

Destarte, da análise dos referidos depoimentos, verifica-se que as testemunhas policiais narraram de forma harmoniosa e convincente todo o contexto de abordagem do réu, não havendo motivos para não dar a eles o devido crédito, não havendo qualquer indício nos autos de injusta incriminação de inocentes. Em contrapartida, não demonstrou o réu motivos plausíveis pelo qual estivesse sendo acusado injustamente.

Assim, não há qualquer verossimilhança na versão do acusado de que os policiais o incriminaram de maneira injusta, de modo que tal versão encontra-se isolada nos autos.

Ademais, próprio réu não destacou qualquer motivo pelo qual os policiais agiriam de tal maneira.

Nesse diapasão, observo que as testemunhas de defesa apresentaram versão contraditória sobre os fatos.

A testemunha Allan afirmou que a abordagem policial sobre o réu aconteceu em um beco, defronte a casa da sua mãe, e que o acusado estava passando pelo local, andando, quando um policial o abordou e determinou que retornasse para o corredor de onde tinha vindo. Já a testemunha Kely disse que, quando da abordagem policial, o acusado estava parado em uma praça, sobre uma bicicleta, conversando com amigos. Deste modo, as versões apresentadas pelas testemunhas defensivas são conflitantes, pois, enquanto Allan falou que viu o réu ser abordado enquanto estava andando a pé pelo beco, sem qualquer bicicleta, Kely disse que o réu foi abordado enquanto estava sobre a bicicleta, sendo que os policiais falaram para ele sentar no chão, sobre as mãos.

Ressalta-se, ainda, que Allan não fez qualquer menção sobre o acusado estar próximo de uma bicicleta quando do momento da abordagem, sendo que Kely, ao ser questionada

por qual motivo Allan nada falou sobre a bicicleta, somente disse, de forma genérica, que o réu deixou a bicicleta no canto da praça.

Neste interregno, não há qualquer motivo capaz de afastar a credibilidade dos depoimentos das testemunhas policiais. Não há indício, nos autos, de que estes tivessem motivo particular ou injusto para incriminar falsamente o réu. Ademais, são servidores públicos com a função de prevenir e reprimir a prática de crime, de maneira que seria um contrassenso atribuir-lhes a função de combate a delitos e, posteriormente, retirar a credibilidade de seus depoimentos.

"O depoimento de policial, mesmo participante da diligência do flagrante, quando coerente e seguro, é tão valioso como qualquer outro" (RT 593/423).

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade das testemunhas em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador" (RT 616/287).

Portanto, da análise dos referidos depoimentos, verifica-se que as testemunhas narraram de forma harmoniosa e convincente a ação criminosa do acusado, sendo encontrada a sacola por ele dispensada momentos antes da abordagem policial, onde estava a droga apreendida, de modo que restou patente a propriedade da totalidade da droga pelo réu.

Em seu interrogatório, o acusado negou os fatos narrados na denúncia. Afirmou que estava na praça, parado, conversando com amigos, quando os policiais chegaram atirando para o alto e, sem qualquer motivo aparente, foi abordado, sendo questionado onde estava a droga e o celular e que, logo em seguida, também sem motivo, foi colocado em uma viatura e levado para o 5º DP.

Disse o réu, ainda, que, ao chegar ao 5º DP, viu os policiais retirando a sacola com as drogas do interior do baú da motocicleta.

No entanto, durante interrogado na fase policial, logo após a abordagem, o acusado preferiu permanecer em silêncio, de modo que, caso estivesse sendo acusado injustamente de crime que não cometeu, não é crível que, na primeira oportunidade que tivesse, perante a autoridade policial, não contasse a sua versão dos fatos, preferindo ficar calado, desejando manifestar-se sobre os fatos somente na fase judicial.

Nesse passo, verifico que a versão apresentada pelo acusado restou enfraquecida, cabendo ressaltar que a prova trazida aos autos pela D. Defesa não teve o condão de infirmar toda a prova produzida na instrução criminal.

No mais, também não merece acolhimento a tese defensiva de que o fato de ter ocorrido o lapso temporal de uma hora entre o momento da ocorrência e a sua comunicação na delegacia coloca em dúvida a ação policial.

Desta forma, observa-se que a D. Defesa questionou de forma genérica que os policiais não conseguiram explicar o lapso temporal entre o momento da ocorrência e a sua comunicação à autoridade policial, de modo que a testemunha Leonardo foi clara ao dizer que levou o tempo normal do local dos fatos até à delegacia.

Assim, não há qualquer desproporção no lapso temporal de uma hora entre o momento da ocorrência e a sua comunicação à autoridade policial, destacando-se que a defesa não trouxe qualquer prova que demonstrasse que o aludido tempo foi devido a qualquer ilegalidade na abordagem e prisão do acusado, não passando, assim, de mera conjectura.

De mais a mais, em atenção à quantidade de droga apreendida, bem como à sua disposição, acondicionada separadamente, e à conduta do acusado, é forçoso reconhecer a destinação comercial do entorpecente apreendido e, conseqüentemente, o animus de traficar do acusado.

No caso em análise, o réu trazia consigo a droga, ou seja, praticou uma das ações previstas no caput do tipo penal, estando, portanto, incurso na prática do crime de tráfico e sujeito às penas a ele culminadas, mesmo que não tenha sido preso em flagrante fazendo a efetiva comercialização do entorpecente.

A atual e predominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a configuração do delito de tráfico não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga. Basta que a traga consigo, especialmente em

significativa quantidade, circunstância que evidencia o comércio clandestino.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.

(...) 3. É firme o entendimento desta Corte Superior de que o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento." (STJ - AgRg no HC: 667338 SP 2021/0151627-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/06/2021,

T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) Outrossim, é cediço que para a consumação do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, que vale recordar, se trata de um tipo misto alternativo (crime de ação múltipla ou de conteúdo variado), basta o cometimento de apenas um de seus verbos, quais sejam os de importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, afigurando-se, assim, o que se denomina dolo genérico. (...) Conclui-se, assim, que o cometimento do crime de tráfico torna despicienda a própria venda, posto que o crime se consuma com o simples "guardar", "portar" ou "trazer consigo." (STJ - AREsp: 1689986 AM 2020/0085766-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 12/02/2021)

In casu, as provas produzidas em Juízo são firmes e seguras ao apontar o acusado como sendo autor do delito de tráfico de drogas.

Portanto, comprovadas autoria e materialidade delitivas e, não incidindo na espécie nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, é imperativo condenar o réu pelo crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo à aplicação das penas.

Na primeira fase, atento-me ao disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 combinado com o artigo 59, do Código Penal. Assim, observo que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, de modo que fixo a pena no mínimo legal, ou seja, seja 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, de modo que mantenho pena do réu em 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, por fim, anoto estar presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Isto porque, o réu é tecnicamente primário e não há qualquer elemento indicativo de que se dedique às atividades criminosas, bem como integre organização criminosa. Desta feita, presentes os requisitos legais, a pena deve ser reduzida no patamar de 2/3. Portanto, fixo a pena por definitivo em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Cada dia-multa será fixado no mínimo, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas da ré.

Anoto, no entanto, a possibilidade de se aplicar ao acusado o benefício da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, tendo em vista que ele preenche os requisitos do art. 44, do Código Penal.

O Senado Federal, por meio da Resolução n.º 5/12, retirou a vedação contida no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, permitindo aos condenados por tráfico de entorpecentes a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. A jurisprudência também já se estabeleceu nesse mesmo sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO). SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da expressão 'vedada a conversão em penas restritivas de direitos', constante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, bem como da expressão 'vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos',

contida no art. 44 do mesmo diploma legal, por ofensa ao princípio constitucional da individualização da pena, sendo possível a pena substitutiva aos traficantes de drogas, desde que preenchidos os pressupostos do art. 44 do Código Penal. 2. No caso concreto, mostra-se viável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos aos agravados, condenados a pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, com circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal favoráveis e sendo pequena a quantidade de material tóxico apreendido - 20 (vinte) pedras de crack e 1 (uma) porção de Cannabis Sativa L. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg. No REsp 1.330.133-RS, 5ªT., rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 05/02/13. Precedentes: STJ HC 230.817-SP, STJ HC 273.633-SP, STJ HC 226.312-MT)

E, ainda, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento acerca da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos quando se tratar de tráfico privilegiado, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena. Se não, vejamos:

"Habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Paciente condenado à pena de um ano e oito meses de reclusão. Regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena. Possibilidade. Paciente que cumpre os requisitos previstos no art. 33, § 2º, "c", do Código Penal. 4. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. Aplicação das Súmulas 718 e 719. 5. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade. Precedente do Plenário (HC n. 97.256/RS). 6. Necessidade de análise dos requisitos dispostos no art. 44 do CP. 7. Superação da Súmula 691. Manifesto constrangimento ilegal. 8. Ordem concedida de ofício para fixar o regime aberto de início do cumprimento da pena e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Criminais." (HC 133.028 -SP - Min. Gilmar Mendes - Julg. 12.04.2016)

Portanto, no caso dos autos, a substituição se mostra suficiente e a medida socialmente recomendável, motivo pelo qual substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

A primeira restritiva consiste no pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo em favor de instituição pública ou privada de destinação social a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme art. 45, parágrafo 1º c.c art. 44, § 2º do Código Penal.

A segunda restritiva consiste em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de prestação de serviços à comunidade ou entidade pública na forma a ser disciplinada pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme art. 46 do Código Penal.

Em caso de descumprimento do benefício ora concedido, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, o que faço para CONDENAR o acusado LEONARDO SANTOS LUZ, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, ante a ausência de elementos demonstrativos sobre a capacidade financeira do réu, pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", c/c § 4º do mesmo artigo, ambos da Lei 11.343/2006.

Substituo em favor do réu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo em favor de instituição pública ou privada de destinação social a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme art. 45, parágrafo 1º c.c art. 44, § 2º do Código Penal, e em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de prestação de serviços à comunidade ou entidade pública na forma a ser disciplinada pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme art. 46 do Código Penal.



Tendo em vista o regime inicial para cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, o réu poderá recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, anatem-se as condenações definitivas no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal. Proceda-se à destruição das drogas apreendidas, caso referida providência ainda não tenha sido determinada, nos termos do art. 50, § 3º, da Lei 11.343/06; com o trânsito em julgado, proceda-se à destruição das amostras guardadas para a contraprova, certificando-se nos autos, consoante art. 72 da Lei 11.343/06. Oportunamente, expeça-se o necessário para a cobrança da multa penal imposta. Deixo de condenar o réu no pagamento das custas processuais, haja vista ser beneficiários da assistência judiciária gratuita.

P.I.C.

Santos, 30 de maio de 2022.

Leonardo de Mello Gonçalves

Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA